

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협회의 소의 이익)>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제01절 행정심판전치주의>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제03절 관할법원>

[기출][2009-1]취소소송의 제기요건(소송요건)(대상적격, 원고적격, 피고적격, 소의 이익, 제소기간, 행정심판전치주의, 관할법원)

《【문제1】 취소소송의 제기요건(소송요건)에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 취소소송의 제기요건(소송요건)(대상적격, 원고적격, 피고적격, 소의 이익, 제소기간, 행정심판전치주의, 관할법원)

I. 문제 제기

- 본 문제는 행정소송법상 가장 전형적인 항고소송인 <취소소송의 적법성 요건(소송요건)>에 대하여 상세히 논하는 데 있다. 취소소송이 적법하게 제기되어 본안 심리로 나아가기 위해서는 법이 정한 일정한 요건들을 모두 충족해야 하며, 이러한 소송요건의 구비 여부는 법원의 직권조사 사항으로, 흠결 시에는 소가 부적법 각하된다. 이하에서는 취소소송의 주요 소송요건들을 법적 근거와 학설 및 판례의 태도를 중심으로 구체적으로 논한다.

II. 소송요건의 종류 및 내용

1. 대상적격

(1) 의의

- 대상적격은 취소소송의 대상이 되는 행정작용의 자격에 관한 요건으로, 행정소송법 제19조 본문에 따라 처분등만이 취소소송의 대상이 될 수 있다. 처분등의 정의는 같은 법 제2조 제1항 제1호에 규정되어 있다.

(2) 판단 기준

- 취소소송의 대상이 되는 처분이 되기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

① 행정청의 행위

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청은 국가나 공공단체의 의사를 결정하여 외부에 표시하는 기관을 의미한다.

② 구체적 사실의 법집행으로서 공권력 행사 또는 거부

- 처분은 구체적인 사건에 대하여 법률을 집행하는 행위여야 하며, 그 성격은 공권력의 행사이거나 이에 준하는 행정작용이어야 한다. 거부행위의 처분성을 인정하기 위해서는 신청인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되어야 한다. 신청권이 없는 단순한 요청에 대한 거부는 원칙적으로 처분성이 부정된다.

③ 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래

- 가장 중요한 기준으로서, 그 행위가 국민의 법률상 지위(권리 또는 의무)에 직접적으로 변동을 초래해야 한다. 이 요건을 충족하지 못하는 내부 행위, 사실 행위 등은 원칙적으로 처분성이 부정된다.

(3) 판례의 경향

- 판례는 국민의 권리구제 확대를 위해 처분 개념을 탄력적으로 해석한다. 법규명령 형식의 행정규칙이나 행정계획의 경우에도 별도의 집행 행위가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 때에는 처분성을 인정하는 경향을 보인다(예 : 고시나 공고). 또한, 거부행위의 처분성 인정 요건인 신청권의 인정 범위도 확대하는 추세이다.

2. 원고적격

(1) 의의

- 원고적격은 소송을 제기하여 판결을 받을 수 있는 자격, 즉 소송을 통해 침해된 자신의 권리 또는 법률상 이익의 구제를 받을 자격을 의미하며, 행정소송법 제12조에 규정되어 있다.

(2) 법률상 이익의 의미

- 원고적격이 인정되는 법률상 이익이란 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의해 보호되는 개별적, 구체적, 직접적인 이익을 의미한다. 단순한 사실상의 이익이나 경제적인 이해관계는 포함되지 않는다.

① 처분의 직접 상대방

- 처분의 직접 상대방은 해당 처분에 의해 권리 또는 의무에 직접적인 변동을 받으므로, 그 처분의 위법성을 다룰 법률상 이익이 추정되어 원고적격이 인정되는 것이 일반적이다.

② 제3자 (인인소송, 경원자소송 등)

- 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자의 경우에도 그 처분으로 인해 법률상 이익을 침해당한 경우 원고적격이 인정될 수 있다. (i) 경원자소송 : 복수 신청인 중 한 사람에게만 면허 등 수익적 처분을 발령함으로써 탈락한 다른 신청인의 이익을 침해한 경우, 탈락한 신청인은 인용처분을 받은 자의 처분의 취소를 구할 원고적격이 있다(특허의 대립관계). (ii) 인인소송 : 처분이 제3자에게 미치는 영향이 당해 처분의 근거 법령이 보호하는 이익에 해당할 경우 원고적격이 인정된다(예 : 환경영향평가 대상 지역 주민의 환경상 이익).

(3) 판례의 경향

- 판례는 원고적격 인정 범위를 점차 확대하여, 환경영향평가법 등 공익 관련 법규에서 규정하는 공익 속의 개인적 이익이나 법률상 보호할 가치가 있는 이익까지 법률상 이익에 포함시키는 적극적인 추세를 보인다.

3. 피고적격

(1) 의의

- 피고적격은 소송에서 피고가 될 수 있는 자격에 관한 요건으로, 행정소송법 제13조에 규정되어 있다. 취소소송은 해당 처분을 행한 행정청을 피고로 한다.

(2) 판단 기준

① 대외적으로 처분 명의를 표시한 행정청

- 처분을 행한 행정주체(국가나 공공단체)가 아닌, 대외적으로 자신의 명의를 표시하여 처분을 행한 행정청이 피고가 된다. 이는 소송 수행의 편의와 재처분 의무의 이행 확보를 위한 것이다.

② 소속 기관의 장

- 국가나 공공단체의 기관이 아닌 소속 기관의 장이 처분 명의를 표시한 경우에도, 그 처분을 한 행정청을 피고로 한다.

4. 협의의 소의 (권리보호의 필요)

(1) 의의

- 협의의 소의는 소송을 통해 원고가 주장하는 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 실익이 있느냐에 관한 요건이다. 설령 처분이 위법하더라도, 소송을 통해 처분을 취소할 필요가 없거나 취소할 실익이 없는 경우 소의가 부정된다(행정소송법 제12조).

(2) 판단 기준

① 처분의 효력 소멸

- 취소소송 중 해당 처분의 효력이 소멸하여 처분 취소의 목적이 달성된 경우 원칙적으로 소의가 부정된다. 다만, 취소판결을 통해 회복될 수 있는 법률상 이익이 남아 있는 경우에는 예외적으로 소의가 인정된다(예 : 가중 요건으로서의 전과가 남아 있는 경우).

② 동일한 처분의 반복 가능성 (반복 위험성)

- 처분의 효력이 소멸했더라도, 그 처분이 반복될 위험이 있고, 법적 견해의 통일을 얻는 것이 중요한 경우(행정소송법 제12조 단서의 예시적 규정), 소의가 인정될 수 있다. 이는 반복 위험성이 있거나, 처분 취소로 인해 침해되는 공익보다 개인의 권리 구제 필요성이 큰 경우에 한정하여 엄격하게 적용된다.

5. 제소기간

(1) 의의

- 제소기간은 취소소송을 제기할 수 있는 법정 기간이며, 소송의 남용을 방지하고 행정법 관계의 조속한 확정을 위한 소송 요건이다.(행정소송법 제20조)

(2) 기간

① 안 날부터 90일 이내

- 처분이 있음을 안 날(현실적으로 안 날)부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 이때 안 날의 판단 기준은 행정처분서의 도달 여부뿐만 아니라, 일반인의 주의력으로 처분의 존재를 인식할 수 있었던 시점까지 포함하여 해석된다.

② 있는 날부터 1년 이내

- 처분이 있는 날(불특정 다수인을 위한 고시 등은 효력 발생일)부터 1년 이내에 제기하여야 한다. 이는 안 날 여부와 관계없이 적용되는 최장 제소기간이다.

③ 불변기간

- 위 기간은 법원이 그 기간을 연장하거나 단축할 수 없는 불변기간이며, 천재지변 등 당사자가 책임질 수 없는 사유가 있는 때에 한하여 추후 보완이 허용될 수 있다.

6. 행정심판 전치주의

(1) 의의

- 행정심판 전치주의란 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거치도록 하는 제도이다. 이는 사법 구제 이전에 행정부 스스로 문제를 해결할 기회를 주어 행정의 자율성을 보장하려는 취지이다.

(2) 현행법상 원칙

- 현행 행정소송법 제18조 제1항 본문에 따라, 행정심판을 거치지 아니하고도 취소소송을 제기할 수 있는 임의적 전치주의가 원칙이다.

(3) 예외 (필요적 전치주의)

- 행정소송법 제18조 제1항 단서에 따라 다른 법률에 대해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 명시적인 규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 필요적 전치주의가 적용된다. 이 경우 행정심판을 거치지 않고 제기된 소송은 부적법 각하된다.

7. 관할 법원

(1) 의의

- 관할 법원은 소송을 제기해야 할 법원의 종류와 위치에 관한 요건으로, 전속 관할의 성격을 가진다.(행정소송법 제9조)

(2) 판단 기준

① 피고의 소재지

- 취소소송의 피고가 되는 행정청의 소재지를 관할하는 행정법원이 관할 법원이 된다.

② 고등법원 관할

- 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 제기할 수 있다.

III. 소송요건의 심리 및 효과

1. 소송요건의 심리

(1) 법원의 직권조사 사항

- 소송요건은 소송의 적법성 여부를 판단하는 요건으로서, 당사자의 주장에 구애받지 않고 법원이 직권으로 조사하여야 할 사항이다.

(2) 변론주의와 직권탐지주의

- 소송요건의 존부에 관한 사실 인정은 원칙적으로 당사자의 주장과 증거에 의존하는 변론주의가 적용된다. 그러나 법원은 소송요건에 대해서는 직권으로 사실을 조사할 수 있는 직권탐지주의를 보충적으로 적용할 수 있다.

2. 소송요건 흠결의 효과

(1) 각하판결

- 취소소송의 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우에는 본안 심리로 나아가지 않고, 법원은 판결의 형식으로 소를 부적법하다고 하여 각하판결을 내린다.

(2) 재소금지 효력 없음

- 각하판결은 본안 판단을 포함하지 않으므로, 확정되어도 위법한 처분이 적법하게 되는 기판력이 발생하지 않는다. 또한, 소송 요건을 보완하여 다시 소송을 제기할 수 있으며, 재소금지 효력은 발생하지 않는다.

IV 결론

- 취소소송은 행정소송의 핵심적인 유형으로서, 그 적법성을 확보하고 국민의 권리 구제를 실효적으로 달성하기 위해서는 행정소송법이 정한 엄격한 소송요건을 충족해야 한다. 대상적격, 원고적격, 피고적격, 협의의 소익, 제소기간, 관할 등의 소송요건은 모두 법원의 직권조사 사항이며, 이들 요건을 정확히 파악하고 충족시키는 것이 소송 승패를 가르는 중요한 출발점이 된다.